

1003939-20.2022.8.26.0286

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Andrea Leme Luchini

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... afirmativamente à indagação sobre roubo/furto/perda dos documentos e cartões bancários. No tocante à senha, informou que a mantinha anotada junto com ao próprio plástico.

Apesar de não relatar tais fatos na inicial, é possível extrair dos documentos mencionados, bem como da narrativa inicial, que a autora perdeu o cartão juntamente com a senha, que mantinha anotada junto ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu

Foro de Itu

1ª Vara Cível

Rua Luiz Bolognesi, s/n, Itu - SP - cep 13301-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003939-20.2022.8.26.0286 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003939-20.2022.8.26.0286

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Marina Amaral Carvalho de Sousa

Requerido:

Banco do Brasil S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andrea Leme Luchini

Vistos.

MARINA AMARAL CARVALHO DE SOUZA ajuizou a presente AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de BANCO DO BRASIL S.A. Aduz, em síntese, que é correntista do banco requerido, onde mantém conta corrente utilizada para saques e pagamentos de contas. Afirma ser pessoa idosa e, sem muito conhecimento tecnológico, realiza as transações sempre de forma presencial. No dia 24/03/2022, foi informada pelo gerente da conta acerca de movimentação atípica, que destoava do uso regular da correntista. Ato contínuo, a requerente dirigiu-se à casa bancária e pôde constatar a irregularidade das transações, cuja autoria desconhece, que somam o montante de R\$ 37.124,19 (trinta e sete mil cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos). Contestou administrativamente as transações, lavrou boletim de ocorrência e, à solicitação de devolução na via administrativa, obteve resposta negativa. Diante da narrativa, requer: i) a declaração de inexistência dos débitos oriundos das transações contestadas; ii) a condenação do requerido ao pagamento de R\$ 37.124,19 (trinta e sete mil cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos), correspondente à totalidade do que fora retirado de sua conta; iii) indenização a título de danos morais, estimados em R\$ 10.000,00. Com a inicial, juntou procuração e documentos (pgs. 15/39).

Citado (pgs. 45), o réu apresentou contestação (pgs. 46/79). Aduziu preliminar de ausência de interesse de agir e impugnou o pedido de gratuidade processual. No mérito, refutou as alegações iniciais porquanto a autora omitiu informações obtidas pela casa bancária na seara administrativa. Isso porque, à época, foi informado pela autora que houve a perda do plástico, juntamente com a senha nele anotada e, apesar do ocorrido, a requerente não solicitou o bloqueio do cartão. Portanto, as transações foram feitas com uso do cartão e senha e, a seu ver, no caso dos autos, não houve falha na prestação dos serviços, uma vez que há culpa exclusiva da vítima. Discorreu sobre a responsabilidade do cliente com relação ao uso de cartão e senha e sobre o descuido na guarda, que permitiu a utilização por fraudadores. Portanto, afirma não haver defeito na prestação de serviços por parte do banco, sendo exigíveis os valores das transações realizadas. Ao final. Pugnou pela improcedência do pedido. Juntou documentos (pgs. 80/105).

Réplica às pgs. 109/120.

Instadas as partes a se manifestar quanto ao interesse na produção de provas e na designação de audiência de tentativa de conciliação, ambas pugnaram pelo julgamento do feito (pgs. 124/126 e 127/128).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Rejeito a preliminar levantada em resposta.

O réu resiste à pretensão inicial, do que decorre que a busca da tutela judicial é necessária. Os pedidos formulados na peça vestibular foram veiculados por meio de procedimento adequado para o seu trânsito. Presente, assim, o interesse processual, deslocando-se o mais para o exame de mérito.

No mais, rejeito a impugnação da gratuidade de justiça deferida à autora, não havendo que se falar em revogação do benefício. Isto porque as alegações do requerido não vieram acompanhadas de documentos aptos a afastarem a conclusão relativa à hipossuficiência da parte autora. Não obstante, a autora apresentou documentos que comprovam o seu estado de hipossuficiência (pgs. 19/33).

Ultrapassadas as questões preliminares, a matéria debatida nos autos é somente de direito e de fato comprovável por meio de prova documental já acostada aos autos, de modo a autorizar o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

De prêmio, cabe reconhecer que a hipótese tratada nestes autos consiste em evidente relação de consumo, de modo que, estando presentes os requisitos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, em decorrência da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor frente à capacidade técnica e econômica do fornecedor, é de rigor.

Ademais, diante do teor da Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", é pacífico o entendimento de que as operações relativas crédito bancário são protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao mérito, a ação é procedente em parte.

Consta dos autos que foram efetuadas diversas transações financeiras na conta bancária da requerente, por terceiro desconhecido, sem sua autorização ou conhecimento, que destoam completamente do perfil habitual de movimentação bancária.

O banco réu, em contestação, alega que não foi observado o dever contratual de guarda da senha pelo autor. Assim, imputa culpa exclusiva à vítima pelo evento e refuta a hipótese de falha na prestação de seus serviços.

Pois bem.

Restou comprovado pelo requerido que, na seara administrativa, obteve da autora informação acerca da perda do cartão e respectiva senha, frise-se, que a requerente mantinha anotada junto ao plástico.

Consta dos autos (pgs. 87/91) que, ao contestar administrativamente os saques e pagamentos efetuados de forma fraudulenta na sua conta bancária, a autora informou que não estava na posse do cartão. Respondeu afirmativamente à indagação sobre roubo/furto/perda dos documentos e cartões bancários. No tocante à senha, informou

que a maninha anotada junto com ao próprio plástico.

Apesar de não relatar tais fatos na inicial, é possível extrair dos documentos mencionados, bem como da narrativa inicial, que a autora perdeu o cartão juntamente com a senha, que maninha anotada junto ao plástico. Somente com a ligação recebida pelo preposto do banco a requerente se deu conta do ocorrido e solicitou a troca de senha do cartão e da internet (pgs. 97/98).

Por estes fatos, o banco réu não possui responsabilidade, tratando-se de culpa exclusiva da autora. Nesse aspecto, não há falar em medida de segurança passível de evitar o ilícito, haja vista ser de responsabilidade da autora acautelar-se contra a perda de seu plástico, agravada pelo fato de que maninha a senha anotada junto ao mesmo.

No entanto, diversas operações bancárias ilícitas, datadas do período de 15 a 23 de março de 2022, em dissonância com o uso regular da conta pela demandante.

De acordo com os extratos acostados às pgs. 19/26, é possível verificar que a autora efetuava pagamentos de contas por meio de emissão de cheques, nos respectivos valores, além de utilizar a conta para recebimento de proventos de aposentadoria.

A partir do dia 13 de março de 2022, denota-se a estranheza de inúmeras movimentações bancárias efetuadas em conjunto com as de costume.

No entanto, é possível verificar que foram efetuados diversos saques de valores consideráveis, entre R\$ 2.500,00 a R\$ 1.000,00, sequenciais e repetidas vezes, estendendo-se pelos dias seguintes. Foram realizados ainda, diversos pagamentos de impostos referentes à multas de trânsito, também de forma repetida e sequencial no mesmo dia, por diversos dias seguidos.

A responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços amolda-se à Teoria do Risco Profissional, descrita no caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Segundo essa teoria, o fornecedor de produtos ou serviços fica obrigado a suportar os riscos provenientes das atividades empresariais exercidas, independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo para a caracterização da responsabilidade civil.

No caso, a autorização dada pelo banco para o uso do cartão em transações destoantes do padrão de consumo da autora configura falha na prestação do serviço, no que tange à necessária segurança das operações bancárias.

Conforme disposto na Súmula nº 479 do C. STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Desta forma, configura-se a concorrência das responsabilidades, da autora e do réu, pelos danos sofridos pela correntista. Prevalece, no caso, o que disposto no artigo 945 do Código Civil, que assim dispõe:

"Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano".

Evoca-se aplicável o referido dispositivo em caso de falha na prestação de serviço, enquanto regra de distribuição dos deveres contratuais e das responsabilidades decorrentes. Ainda que não se mostre necessária a averiguação de culpa do prestador de serviço para que se responsabilize pela ocorrência do dano, a concorrência de atos culposos da vítima, responsável subjetiva, é motivo para que aquela seja mitigada em seus efeitos.

Em caso semelhante, assim decidiu o C. STJ:

"CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SAQUE DE IMPORTÂNCIA DE CORRENTISTA POR TERCEIRO, COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO. FALTA DE PRECAUÇÃO DO TITULAR, ALIADA À NEGLIGÊNCIA DO BANCO EM AUTORIZAR A TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA CONTA DE POUPANÇA PARA A CONTA CORRENTE, SEM AS CAUTELAS DE PRAXE. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. RESSARCIMENTO REDUZIDO À METADE. I. Situação em que se identifica, com base no voto médio, a concorrência de culpas da autora e do banco, a primeira por entregar o cartão e informar senha a pessoa amiga, que permitiu o acesso a terceiro sobre os dados sigilosos, e do réu por atuar negligentemente quando da solicitação, pelo fraudador, via telefônica, da transferência de valores da conta de poupança para a corrente, o que viabilizou a retirada subseqüentemente. II. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente

provido, para condenar o réu a ressarcir à autora metade dos danos apurados". (REsp 235.385/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, Rel. p/ Ac. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 11/12/2001, DJ 01/07/2004, p. 199).

De igual maneira, decide o Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante em casos semelhantes:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FUNDADA EM COMPRAS REALIZADOS POR TERCEIRO MEDIANTE USO DE CARTÃO DE TITULARIDADE DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PORQUE É DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS, UMA VEZ QUE OS FATOS NARRADOS E OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR QUE AO REALIZAR COMPRA DE AMBULANTE EM VIA PÚBLICA, NÃO SE ATENTOU PARA O FATO DE QUE LHE FOI DEVOLVIDO UM CARTÃO DE OUTRA PESSOA. O VENDEDOR SE APROVEITOU DA SITUAÇÃO PARA APLICAR O CHAMADO "GOLPE DA TROCA DE CARTÕES". RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR NÃO TER AGIDO COM CAUTELA AO AUTORIZAR COMPRAS EM VALORES QUE DESTOAVAM DO PADRÃO DE CONSUMO DIÁRIO DO AUTOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE FLEXÍVEL, O QUE DEVERIA ENSEJAR MAIOR ATENÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOBRE AS OPERAÇÕES REALIZADAS. REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR O BANCO À RESTITUIÇÃO DE METADE DO VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS OCORRIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003024-

18.2020.8.26.0002; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020).

"APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO Ação declaratória e indenizatória Sentença de parcial procedência Insurgências Autor que não reconhece movimentações em sua conta bancária Narrativa autoral vaga e inverossímil que impede a inversão do ônus da prova do art. 6º, inc VIII do CDC Autor que ao aderir ao sistema de cartão de crédito/débito assume a obrigação de guarda e conservação do cartão Operações realizadas com o plástico do cartão com chip e senha Descumprimento do dever de guarda do cartão Concorrência culposa para o evento danoso Culpa concorrente do cliente 7 (sete) compras efetivadas, no mesmo dia, em curto espaço de tempo no mesmo estabelecimento que deveriam ter sido identificadas e bloqueadas pelo sistema de segurança do banco Falha na prestação de serviços Súmula 479 do STJ Culpa concorrente reconhecida Dever de restituição pelo banco de metade dos valores das transações impugnadas Danos morais Inocorrência Ausente abalo de crédito, restrição cadastral, lesão às suas honras objetiva e subjetiva ou cobrança vexatória ou humilhante Não comprovada perda de tempo útil expressiva, como por exemplo, ausência em dia de trabalho ou perda de compromisso Verba sucumbencial e honorários rateados Recurso do réu parcialmente provido e do autor prejudicado". (TJSP; Apelação Cível 1010568-05.2021.8.26.0008; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022).

"Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e morais. Fraude bancária. Golpe da troca de cartões. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do banco. Súmula 479 STJ. Falha na prestação de serviço bancários. Operações impugnadas nos autos que destoam do perfil do consumidor. Reconhecimento, contudo, da culpa concorrente. Conduta do consumidor que contribuiu para o evento danoso, ao não ser diligente na guarda de seu cartão e senha de uso pessoal. Recursos a que se nega provimento". (TJSP; Apelação Cível 1087285-10.2020.8.26.0100; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 02/05/2022). Passa-se à análise dos pedidos inicialmente formulados pelo autor, isto é, a declaração de inexigibilidade dos débitos impugnados e o pagamento de indenização por danos morais.

O autor indicou o valor de R\$ 37.124,19 como o total indevidamente utilizado pelos estelionatários. Desse total, com base na regra do artigo 945 do Código Civil, entende-se como devido à autora a metade (R\$18.562,09 à data do evento), sendo a outra metade de responsabilidade da instituição financeira requerida. Outrossim, ainda que o banco tenha falhado, ao permitir o uso do cartão em

transações destoantes do padrão de consumo de uso do correntista, a verdade é que a autora não zelou pela guarda e senha pessoal do cartão, ônus que lhe incumbe. Portanto, face à culpa concorrente, não se evidencia a possibilidade de indenização a título de dano moral.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com fulcro no art. 355, I do CPC, para DECLARAR inexigível o valor de R\$ 18.562,09 (dezoito mil quinhentos e sessenta e dois reais e nove centavos) referente à metade dos valores retirados da conta bancária da autora mediante fraude e CONDENAR o réu a pagar à autora o referido montante, que deverá ser atualizado e acrescido de juros de 1% ao mês, contados das respectivas datas das retiradas/saques.

Em razão da sucumbência, arcarão as partes com 50% do pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária que, com fulcro no art. 85, §2º do CPC, fixo em 10% do valor da condenação.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Itu, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA